

1001448-98.2017.8.26.0097

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo

Magistrado: DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Comarca: Buritama

Foro: Foro de Buritama

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... tais valores, configuraria a cobrança sobre o tráfico jurídico, baseado em simples contrato, o que é vedado.

As tarifas questionadas TUSD e TUST, bem como os encargos setoriais, remuneram atividades relacionadas à prestação do serviço de fornecimento pelas redes básica e especial e manutenção do próprio sistema.

São, pois, atrelados aos meios utilizados para a prestação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buritama

Foro de Buritama

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Frei Marcelo Manília, 739, Buritama - SP - cep 15290-000

1001448-98.2017.8.26.0097 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001448-98.2017.8.26.0097

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo

Requerente:

Rosa Elidia Caetano Costa

Requerido:

Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9099/95.

Fundamento e DECIDO.

O feito reclama julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os dados trazidos aos autos são bastantes para o conhecimento da questão posta, não havendo necessidade de produzir outras provas, circunstância que vem a dar azo ao princípio da razoável duração do processo (artigos 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 139, inciso II, do diploma processual civil).

Como é cediço, o juiz é o destinatário final da prova, incumbindo-lhe decidir sobre a necessidade, ou não, de dilação probatória mais ampla, ou julgar antecipadamente o pedido. Compete ao magistrado, na condução do processo, deferir e apreciar o arcabouço probatório coligido. Entendendo que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento para o deslinde da questão, não se configura cerceamento de defesa (artigo 371 do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, prevê o artigo 370 do mesmo diploma legal: "Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito" .

Passo à análise das preliminares.

Não é mais cabível a suspensão do processo por força do IRDR nº 2246948-

26.2016.8.26.0000, porque a suspensão dos processos acerca da matéria afetada se deu em 2017, e o CPC determina que, superado o prazo de julgamento do IRDR, de um ano, cessa a suspensão dos processos, em atenção aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da economia e celeridade processual (CF, art. 5º, inciso LXXVIII; e CPC, art. 4º e 6º). Dessa forma, levante-se a suspensão utilizando o código próprio (55555).

Ademais, ainda que se possa alegar a superveniência de ordem de suspensão determinada no Recurso Especial nº 1.734.902-SP (Tema 986 - STJ), nota-se que a ordem de suspensão foi proferida em 2019. O artigo 1.037, §4º do Código de Processo Civil dispõe que "Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus", reprodução quase idêntica à prevista no artigo 980 do CPC, razão pela qual entende-se pela aplicação, por analogia, do previsto no parágrafo único deste artigo.

A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não comporta acolhimento porquanto o sujeito passivo da obrigação tributária é o consumidor final da energia elétrica, ou seja, a parte autora, que assumiu a condição de contribuinte de fato e de direito. Sendo consumidora final da energia elétrica, custeia o ICMS cujo pagamento considera indevido e tem legitimidade para pleitear a cessação das cobranças e a repetição do indébito tributário.

A preliminar de incompetência absoluta, igualmente, não comporta acolhida, vez que a solução da controvérsia prescinde de produção de perícia técnica complexa, sendo absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do diminuto valor da causa. Ademais, os cálculos do eventual crédito da parte autora deverão ser apresentados no momento oportuno, quando da eventual liquidação do julgado.

Do mesmo modo, afasto a preliminar de inépcia e falta de documentos indispensáveis à propositura da ação (comprovações de pagamentos), pois, existindo o direito à repetição do indébito, os valores só serão devidos se comprovados os recolhimentos indevidos, na fase de cumprimento de sentença.

No mais, antes de adentrar no mérito propriamente dito, impende ressaltar que o julgado recente colacionado (Resp 1.163.020/RS) refere-se à decisão tomada pela 1ª Turma do STJ em apertada maioria (resultado de 3 a 2). Cabe também a observação que não serve de precedente vinculante, haja vista que não fora submetido ao julgamento sob o rito de recursos repetitivos.

Tal fato é relevante, mas não o suficiente para justificar a mudança na orientação deste juízo. Assim, por segurança jurídica, mantém-se a orientação que vinha sendo seguida pelo juízo, enquanto não ocorra mudança clara e definitiva de entendimento, pelo STJ ou pelo STF.

Cabe salientar, ademais, que o TJSP, majoritariamente (ainda que não de modo unânime e pacífico) vem seguindo essa orientação, mesmo após o julgamento do REsp 1.163.020/RS: Ap. 1020567-60.2016.8.26.0071, Rel. Heloísa Martins Mimessi, 5ª

Câmara de Direito Público, j. 12/05/2017; Ap. 1030834-73.2016.8.26.0562, Rel. Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 09/05/2017; Ap. 1052518-63.2015.8.26.0053, Rel. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j.

10/05/2017; Ap. 1038964-52.2016.8.26.0562, Rel. Ana Liarte, 4ª Câmara de Direito Público, j. 08/05/2017.

No mérito, a demanda é procedente.

Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito, para o fim de afastar da base de cálculo do ICMS a incidência das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD).

Como cediço, o ICMS caracteriza-se como tributo incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias. O fato gerador é a saída do estabelecimento do contribuinte, sendo devido o imposto somente com a entrega ao seu destinatário, quando ocorre a efetiva transferência da posse ou propriedade. O efetivo consumo, pelo destinatário final, é imprescindível para a caracterização do fato gerador do tributo.

Note-se que o ICMS incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, compreendendo negócio jurídico mercantil. O artigo 1º da Lei Estadual nº 6.374/89 estabelece que:

Artigo 1º - O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incide sobre: (Redação dada ao artigo pela Lei 10.619/00, de 19-07-2000; DOE 20-07-2000) I- operação relativa à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em qualquer estabelecimento; (...)

O termo "circulação" deve ser entendido, conforme lição de Leandro Paulsen, como "a passagem das mercadorias de uma pessoa para outra, sob um título jurídico, sendo irrelevante a mera circulação física ou econômica" (PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de; Impostos: Federais, Estaduais e Municipais, 9ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 253).

Em outros termos, circulação é a mudança da titularidade jurídica do bem, e não a mera movimentação física.

Dessa forma, o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro não configura o fato gerador do ICMS. Nesse sentido, a súmula 166 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Igualmente não configura fato gerador do ICMS os atos de preparação e produção da mercadoria. Isto porque o conceito de mercadoria corresponde à ideia do bem corpóreo (ampliado constitucionalmente para abranger a energia elétrica, malgrado se trate de bem incorpóreo), resultado da atividade "profissional do produtor, industrial e comerciante, tendo por objeto a sua distribuição para o consumo (...) distinguindo-se das coisas que tenham qualificação diversa, como é o caso do ativo permanente".

Logo, conclui-se que apenas a circulação da mercadoria, como resultado da atividade profissional desenvolvida, é que configura fato gerador do ICMS. O fato gerador, portanto, é a saída do estabelecimento do contribuinte com a entrega ao seu destinatário, momento em que ocorre a efetiva transferência da posse ou propriedade.

Veja-se que o consumo efetivo, pelo destinatário final, é imprescindível para a caracterização do fato gerador do tributo.

Portanto, ainda que a preparação, produção e distribuição sejam etapas para o fornecimento de energia elétrica, certo é que são atividades-meio, e, assim, não podem integrar a base de cálculo para o tributo, na ausência de previsão legal. A incidência sobre tais valores, configuraria a cobrança sobre o tráfico jurídico, baseado em simples contrato, o que é vedado.

As tarifas questionadas TUSD e TUST, bem como os encargos setoriais, remuneram atividades relacionadas à prestação do serviço de fornecimento pelas redes básica e especial e manutenção do próprio sistema.

São, pois, atrelados aos meios utilizados para a prestação do serviço, daí o não cabimento de sua consideração na base de cálculo do tributo.

Nesse sentido:

"ICMS. Energia elétrica. Tarifas de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) - Inocorrência de hipótese de incidência que admita utilização dessas tarifas na base de cálculo do imposto. Inexistência de "circulação" de mercadoria. Precedentes. Legitimidade ativa para a repetição. Impossibilidade de condenação em pagamento de honorários contratados com advogado. Recurso fazendário improvido, e recurso da empresa autora parcialmente provido." (Apelação nº 1009577- 98.2015.8.26.0053, rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, j. 14/12/2015).

"APELAÇÃO. Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito. ICMS. Transmissão de energia elétrica Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia Elétrica" TUSD e TUST e encargos de conexão Sentença que julgou procedente a demanda Alegação de ilegitimidade ativa e custo operacional do sistema que deve ser suportado por quem o utiliza Pretensão de improcedência da ação - Inadmissibilidade Transmissão e distribuição de energia elétrica que não compõem o fato gerador do ICMS Legitimidade da empresa autora pacificada em recentes decisões do E. STJ Sentença de primeiro grau que será mantida- Recurso desprovido." (Apelação nº 1019266-69.2015.8.26.0053, rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, j.11/04/2016).

Aplica-se, ainda, ao caso em análise, a Súmula nº 391 do E. STJ: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada".

Na situação dos autos, há circulação econômica com transferência da propriedade da energia elétrica apenas no momento em que esta é efetivamente consumida pelo destinatário, o que não ocorre na fase de transmissão e distribuição, que são meras etapas necessárias à prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Portanto, pelo todo exposto acima, forçoso concluir pela ilegalidade da cobrança do ICMS sobre os valores referentes à TUST e TUSD e demais encargos setoriais, porquanto estão fora do âmbito do tributo.

Sobre o valor a restituir, mister que se adicione correção monetária desde o desembolso de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP até o trânsito em julgado e, a partir de então, deverá ser aplicada a taxa SELIC (que abrange os juros de mora e correção monetária), conforme decidido pelo C.STJ no Recurso Especial nº 1.111.189/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 19) e consoante art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ ("Os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença"), pois, tratando-se de repetição de indébito tributário não tem incidência a Lei 11.960/09.

Os demais argumentos apresentados pela ré não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por esse julgador (art. 489, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ROSA ELIDIA CAETANO COSTA em face do FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para declarar definitivamente a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes que obrigue o autor a proceder ao pagamento do ICMS incidente sobre os valores devidos a título de TUST e TUSD, na instalação elétrica de nº 38408724, definindo-se a base de cálculo do referido tributo como sendo, unicamente, o montante relativo à energia elétrica efetivamente consumida, devendo a ré se abster de praticar medidas coercitivas relativas à referida cobrança. Condene a ré à repetição de indébito pago, devidamente apurado em liquidação de sentença, referente à inclusão na base de cálculo do ICMS dos valores a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) de energia elétrica das mencionadas instalações, respeitada a prescrição quinquenal e desde que comprovados os respectivos recolhimentos, acrescidos de correção monetária e juros de mora como acima exposto. Sem custas e honorários por expressa disposição legal (artigo 55 da Lei 9.099/95). Ficam os litigantes cientes, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou manifestamente protelatórios sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, sem alterações para as partes, arquivem-se os autos digitais, dando-se baixa no distribuidor.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Buritama, 01 de novembro de 2022.